

1501100-98.2021.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Jane Rute Nalini Anderson

Comarca: Jundiaí / SP

Foro: Foro de Jundiaí

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/04/2022

... de possíveis práticas ilícitas relacionadas ao tráfico de substância entorpecente. Entendeu-se não haver flagrante forjado o resultante de diligências policiais após denúncia anônima sobre tráfico de entorpecentes (HC 74.195, rel. Min. Sidney Sanches, 1ª Turma, DJ 13.09.1996). 3. Elementos indiciários acerca da prática de ilícito penal. Não houve emprego ou utilização de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí

Cartório da 3ª. Vara Criminal: Largo São Bento, s/nº, Centro, Jundiaí, Estado de São Paulo.

CEP nº 13201-035. Telefone: (11) 4586-8111, E-mail: jundiai3cr@tjsp.jus.br.

Processo nº 1501100-98.2021.8.26.0544

Página nº de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí

Cartório da 3ª. Vara Criminal: Largo São Bento, s/nº, Centro, Jundiaí, Estado de São Paulo.

CEP nº 13201-035. Telefone: (11) (11) 4586-8111, E-mail:jundiai3cr@tjsp.jus.br.

Processo nº 1501100-98.2021.8.26.0544

Página nº de

Vistos.

ERIC GABRIEL DA SILVA MIGUEL, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 03 de maio de 2021, por volta das 09h00min, na Rua Luiz Henrique Stackflet nº 93, Parque Centenário, nesta cidade e Comarca de Jundiaí, tinha em depósito, para fim de tráfico, 143 porções de cocaína, 117 porções de maconha e 64 porções de "crack", substâncias estas que

causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra a denúncia que guardas municipais foram informados por um popular sobre a existência de entorpecentes na residência do acusado, bem como que eles seriam distribuídos no bairro.

Assim, os agentes municipais se deslocaram até o endereço acima mencionado e, no local, foram recebidos pelo genitor de Eric, que franqueou-lhes a entrada na moradia.

Realizadas buscas no local, os guardas municipais localizaram as drogas acima descritas.

Instado a respeito dos fatos, o réu confessou a traficância.

Assim, pela quantidade e variedade das substâncias entorpecentes e circunstâncias da apreensão, foi preso em flagrante.

Notificado, o réu apresentou defesa prévia.

Recebida a denúncia e analisada a defesa apresentada, foi designada audiência de instrução e julgamento.

Na audiência, ouviram-se duas testemunhas, após o que o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em debates, o Promotor de Justiça analisou a prova e pediu a condenação do réu nos exatos termos da denúncia, porquanto devidamente demonstradas a autoria e a materialidade delitivas. Requereu, ainda, a fixação de regime inicial fechado e a não aplicação do redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

A defesa, em preliminar, arguiu o que segue: ilicitude da prova, ante a ilegalidade da prisão efetuada pelos guardas municipais, os quais não têm legitimidade para efetuar diligências afetas somente à Polícia Judiciária, conforme dispõe o artigo 144 da Constituição Federal. Sustentou, ainda, que a prisão do réu decorreu de denúncia anônima, o que afasta a situação de flagrância; nulidade do processo tendo em vista a invasão de domicílio sem ordem legal, porquanto não há prova de que a entrada dos guardas municipais foi franqueada pelo dono do imóvel. Salientou, ainda, que as buscas realizadas no imóvel não foram acompanhadas pelo réu ou qualquer outro morador. No mérito, bateu-se por absolvição, sob o fundamento de insuficiência probatória para o édito condenatório. Para tanto, alegou que a palavra de policiais devem ser recebidos com reserva, ante o interesse que tem em justificar sua conduta. Sustentou, ainda, que tais testemunhas apresentaram depoimentos contraditórios. Em caso de entendimento diverso, postulou a desclassificação do delito para uso próprio; fixação da pena-base no mínimo legal; redução da pena de acordo com o previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas; imposição de regime inicial aberto; substituição da corporal por restritivas de direitos e o direito de recorrer solto..

RELATADO.

DECIDO.

Afasto as preliminares de nulidade suscitadas pela defesa.

Não há falar em ilegalidade na atuação dos guardas municipais quando da prisão em flagrante do acusado.

Com efeito, "in casu", não houve qualquer investigação policial exercida pelos guardas municipais, mas sim situação de flagrância, o que autoriza a prisão, vez que o tráfico de substância entorpecente é crime de natureza permanente. Assim, permanecendo o agente em situação de flagrância, não há qualquer ilicitude no fato dos guardas municipais terem dado voz de prisão ao acusado e apreendido a droga. Ademais, conforme dispõe o artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode realizar prisão em flagrante.

E ainda que se desconsiderasse o enquadramento dos guardas municipais como "autoridades policiais" - a quem cabe o dever de efetuar prisões em flagrante - permaneceria a eles a possibilidade de realizá-las, uma vez que o dispositivo legal acima referido permite, de forma expressa, tal faculdade a "qualquer do povo".

Assim já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça: "Tráfico de drogas (artigo 33 da Lei 11.343/06). Nulidade do auto de prisão. Flagrante realizado por guardas municipais. Possibilidade. Inteligência do artigo 301 do Código de Processo Penal. Mácula inexistente. 1. Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal,

qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, razão pela qual não há óbice à sua realização por guardas municipais. Precedentes". (HC nº 296.728/SP, 5ª Turma, rel. Min. Jorge Mussi, DJe 02/09/2014).

Note-se, outrossim, que a prisão foi devidamente comunicada à autoridade judiciária competente, que lavrou o auto de prisão respectivo e firmou a nota de culpa ao réu, ratificando e convalidando, portanto, os atos praticados pelos agentes municipais.

Embora o artigo 144, § 8º, da Carta Magna, estabeleça como função da guarda municipal – relativamente ao município – a “proteção de seus bens, serviços e instalações”, não há proibição na prisão em flagrante de pessoas suspeitas por prática de crimes, bem como a apreensão de bens relacionados aos delitos.

Entendimento contrário, como quer a defesa, implicaria equivocada proibição às guardas municipais, sem qualquer base normativa ou justificativa razoável.

Não é caso, outrossim, de nulidade por ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio na diligência que culminou com a apreensão do entorpecente, uma vez que se trata de crime permanente, o que afasta qualquer ilicitude na ação dos guardas municipais.

Para a caracterização do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, basta a verificação de apenas uma das figuras constantes no “caput” do artigo 33 da Lei de Drogas especialmente a de ter em depósito substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica.

Ademais, a garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio comporta exceções, como no caso de flagrante delito.

Com efeito, não há falar em nulidade das provas por violação de domicílio ou em ilicitude das provas por derivação, porquanto nada impede que um policial adentre em residência alheia, seja durante o dia ou à noite, contra a vontade do morador, para efetuar prisão em flagrante, ainda mais porque a referida inviolabilidade comporta exceção quando se tratar de hipótese de flagrante delito ou quando existe um crime em andamento.

Com efeito, “A Constituição não proíbe a entrada em casa alheia, ainda que à noite, se houver caso de flagrante delito (art. 5º, XI), ocasião em que se poderá efetuar a busca e apreensão. É o que pode ocorrer, inclusive, nas hipóteses de crimes permanentes, em que a consumação se prolonga no tempo, como no caso de “ter em depósito” ou “guardar” substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica (art. 12 da Lei nº 6.368, de 21/10/76)” (cf. Júlio Fabbrini Mirabete, Código de Processo Penal Interpretado, 10ª ed., Atlas, 2003, nº 241.2, pág. 625). E, in casu, sendo hipótese de crime de tráfico de entorpecentes, sob a modalidade “ter em depósito”, o qual, sendo crime permanente, admite a prisão em flagrante em qualquer momento, presente a situação de flagrância, o que legitimou o ingresso dos agentes municipais na residência do réu.

Ensina Guilherme de Souza Nucci, “Em casos de crimes permanentes (aqueles que se prolongam no tempo), como é o caso do tráfico de entorpecentes, na modalidade 'ter em depósito' ou 'trazer consigo', pode o policial penetrar no domicílio efetuando a prisão cabível” (Código de Processo Penal Comentado, 8ª ed., RT, 2008, pág. 530, nº 31).

Outro não é o entendimento do Pretório Excelso, “1. A questão controvertida consiste na possível existência de prova ilícita ('denúncia anônima' e prova colhida sem observância da garantia da inviolabilidade do domicílio), o que contaminaria o processo que resultou na sua condenação. 2. Legitimidade e validade do processo que se originou das investigações baseadas, no primeiro momento, de 'denúncia anônima' dando conta de possíveis práticas ilícitas relacionadas ao tráfico de substância entorpecente. Entendeu-se não haver flagrante forjado o resultante de diligências policiais após denúncia anônima sobre tráfico de entorpecentes (HC 74.195, rel. Min. Sidney Sanches, 1ª Turma, DJ 13.09.1996). 3. Elementos indiciários acerca da prática de ilícito penal. Não houve emprego ou utilização de provas obtidas por meios ilícitos no âmbito do processo instaurado contra o recorrente, não incidindo, na espécie, o disposto no art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal” (RHC 86.028/RS, rel. Min. Ellen Gracie, 2ª T., DJ de 22/08/08).

E mais, “O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso

forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010). Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. Precedentes desta Corte. 4. No caso concreto, diante do consentimento válido de seu filho maior de idade para a entrada dos policiais no apartamento e do fato de que a busca domiciliar, a despeito de não amparada em mandado judicial, foi precedida de denúncia anônima de tráfico, de diligências prévias da autoridade policial e da descoberta de drogas em poder de seus filhos, o que caracteriza um quadro de flagrante de crime permanente, não há como se reputar ilegal a apreensão do dinheiro encontrado no apartamento, que constituiu descoberta fortuita válida e legal. 5. Recurso ordinário a que se nega provimento". (STJ, RMS nº 65.115/SP, 5ª Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 11/02/2021). Assim também vem se posicionando o Superior Tribunal de Justiça, "(...) 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade "guardar" é do tipo permanente, cuja consumação se protraí no tempo, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, independente de mandado judicial. Ademais, no caso dos autos, verifica-se da peça acusatória, que os policiais militares estavam em patrulhamento pela região e receberam informação de que a paciente estaria vendendo drogas naquela via pública e se deslocaram para o local, surpreendendo-a em frente ao imóvel. A paciente, ao ver os policiais, jogou as drogas na calçada (6 porções de skunk), mas foi detida, admitindo a prática do crime e afirmando, inclusive, que havia mais drogas em sua residência. Assim, os policiais, entraram em sua residência, com sua anuência, e encontraram mais drogas, as quais estavam fracionadas e embaladas individualmente, confirmando a prática do delito e realizando a prisão em flagrante da paciente. Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, o que autoriza a atuação policial, não havendo falar em nulidade da prisão em flagrante no interior do domicílio dos agentes, por ausência de mandado judicial". (HC nº 629.141/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Pacionirk, 5ª Turma, DJe 22/03/2021).

Reconhecida, portanto, a convergência de suporte para o ingresso no imóvel, não há que se falar em violação da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio e, por consequência, em ilicitude probatória. Ademais, a prova coligida demonstrou que o genitor do acusado autorizou a entrada dos guardas municipais no imóvel, não se podendo invalidar a palavra dessas testemunhas.

Afastada as questões prejudiciais, passo ao exame do mérito.

Diante da prova existente verifica-se que a denúncia é procedente.

A materialidade está devidamente demonstrada pelo auto de exibição e apreensão das drogas, bem como pelos laudos de exame químico-toxicológico, provisório e definitivo (fls. 20/22 e 171/173), os quais confirmam que as substâncias apreendidas são entorpecentes que causam dependência física e psíquica e pelos demais documentos acostados aos autos.

Incontroversa a prova de autoria.

Tanto na fase administrativa como em Juízo o réu fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Fortalecendo a prova de autoria, as testemunhas Gabriel da Cunha Braga e Anderson Moreira, guardas municipais que tomaram parte nas diligências, sempre que ouvidas,

narraram como se deu o encontro das substâncias tóxicas em poder do réu. Relataram, ainda, que foram comunicados por um munícipe sobre a existência de drogas na residência do acusado. Dirigiram-se ao local e tiveram a entrada no imóvel franqueada pelo genitor do réu, que se apresentou como proprietário. Realizadas buscas, apreenderam diversas porções de entorpecentes no quarto de Eric, que admitiu a propriedade das mesmas. Não conheciam o acusado antes dos fatos. Como se vê, as palavras dessas testemunhas, ao contrário do alegado pela defesa, são suficientes para corroborar a acusação. Além do mais, trata-se de depoimentos coerentes, harmônicos e verossimilhantes, que não demonstram o propósito de querer enganar nem dão motivo de suspeição. Como seu valor não se põe em dúvida, eles podem ser considerados fonte de convicção (ver: CF, 93, IX; CPP, artigo 155, caput; RTJ, 143/160 e 201/637).

Quando não bastasse, em casos de aplicação da Lei de Drogas, a jurisprudência amplamente majoritária não tem feito restrição ao testemunho de qualquer policial, quando o seu depoimento estiver em harmonia com os demais elementos de prova. Mas não é tudo. Para enfraquecê-lo é imperioso demonstrar motivo sério e concreto, sendo insuficiente a mera alegação de parcialidade desacompanhada dos respectivos elementos de convicção. E não haveria motivo de eventual trama dessas testemunhas para incriminar falsamente os acusados, restando demonstrada nos autos a traficância.

Nesse sentido, “A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado. É preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas” (STF, HC 74.522-9/AC, 2ª Turma, rel. Min. Maurício Corrêa, DJU, 13/12/96, pág. 50.167).

Note-se, agora, que as substâncias tóxicas foram apreendidas divididas e acondicionadas em porções, para a venda no varejo, configurando a entrega para o consumo ou tráfico ilícito de drogas.

A conduta de qualquer dos verbos contidos no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, sendo o dolo sempre genérico. Por isso, dispensável a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga, sendo bastante a prova do conjunto de indícios e presunções envolvendo o acusado.

É possível, em consequência, o uso de prova indiciária, a qual também está em harmonia com o princípio do livre convencimento do juiz (cf. artigos 239 e 157, ambos do Código de Processo Penal).

Não é caso de desclassificação do delito para uso próprio, porquanto de acordo com o disposto no artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, a quantidade da substância apreendida, as circunstâncias social e pessoal do agente, assim como as condições em que se desenvolveu a ação, devem ser analisadas para determinar se as substâncias se destinavam ao consumo pessoal ou não. E, no presente caso, cabalmente demonstrada a hipótese do tráfico de drogas, especialmente diante da significativa quantidade de entorpecentes, incompatível com o uso exclusivo de uma única pessoa.

Dessa forma, insubsistente a alegação da defesa de fragilidade das provas, porquanto bem caracterizado o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Concluindo, o conjunto probatório é suficiente para dar credibilidade à acusação.

Ante o exposto, afastadas as preliminares, julgo PROCEDENTE a denúncia e o faço para CONDENAR o réu ERIC GABRIEL DA SILVA MIGUEL, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

Observando os elementos norteadores contidos no artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, a fixo a pena-base acima do patamar mínimo, no percentual de 1/5 (um quinto), somando 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, tendo em vista que a quantidade e variedade das substâncias entorpecentes apreendidas em poder do réu.

Note-se que a “Quantidade e qualidade da droga apreendida é circunstância que deve ser sopesada na primeira fase de individualização da pena, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006” (cf. STF, 2ª Turma, RHC 111.440/DF, rel. Min. Gilmar Mendes,

DJe-094, 15/05/2012).

Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Tendo em vista a quantidade de droga apreendida e a primariedade do acusado, reduzo a sanção de 1/4 (um quarto), ante o disposto no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, resultando 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa.

Embora seja significativa a quantidade de tóxico apreendida em poder do réu, não há prova nos autos de que ele se dedique a atividades criminosas ou que pertença a organização voltada a prática de delitos.

Nesse sentido julgado do Tribunal de Justiça: "REVISÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Não cabimento. Desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06. Impossibilidade. Condenação em plena consonância com o conjunto probatório. Dosimetria. Cabível a redução da pena imposta. Aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Requerente primário, surpreendido cultivando quantidade não excessiva de plantas de maconha, sem demonstração de que se dedique a atividades ilícitas ou de que pertença a organização criminosa. Pena redimensionada. Viável a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Pedido julgado parcialmente procedente" (Revisão Criminal nº 2117303-69.2021, 8º Grupo de Câmaras, Rel. Desembargador Leme Garcia, j. 17/03/2022).

No mesmo teor vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, "1. Quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando ela atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 2. In casu, as instâncias ordinárias fundamentaram expressamente a majoração da pena-base, considerando a grande quantidade da droga apreendida - 17.305 gramas de cocaína -, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Daí, não se mostra desproporcional ou desarrazoada, porquanto fundamentada a fração em elementos concretos e dentro do critério da discricionariedade vinculada do julgador. 3. A ciência do agente de estar a serviço de grupo criminoso voltado ao tráfico internacional de drogas é circunstância apta a justificar a redução da pena em 1/6, pela aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (Precedentes)" (AgRg no Aresp 1742916/SP, 5ª Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 08/03/2021).

Fixo o regime semiaberto para início de desconto da pena corporal.

O réu poderá apelar em liberdade, porquanto respondeu solto ao processo.

Autorizo a destruição do entorpecente apreendido nos autos, oficiando-se.

Assim, fica o réu ERIC GABRIEL DA SILVA MIGUEL, condenado à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa, como incurso no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, seja o nome do réu lançado no rol dos culpados.

P.I.C.

Jundiaí, 8 de abril de 2022.

Jane Rute Nalini Anderson
Juíza de Direito